

1503310-30.2021.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... foram apreendidos outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes em poder do réu e nenhum outro elemento foi trazido aos autos de forma a indicar a efetiva prática do tráfico de drogas por ele na data dos fatos.

Não se desconhece que para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente seja preso no ato da mercancia ou após vender ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503310-30.2021.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503310-30.2021.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284239/2021 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 20890454 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 229/21/616 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2284239 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

PABLO ROGERIO FIGUEIREDO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

PABLO ROGÉRIO FIGUEIREDO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06 e art. 180, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque em 18 de outubro de 2021, por volta de 11h10, na avenida 17 particular, nº 1850, Consolação, nesta cidade e comarca de Rio Claro, o acusado, teria tido em depósito e guardado drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no caso, 07 porções de crack, produto da cocaína, com peso líquido de aproximadamente 1,35g.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado PABLO ROGÉRIO FIGUEIREDO, teria recebido e ocultado coisas que saberia serem produto de crime, quais sejam, duas cadeiras de escritório (uma verde e a outra marrom), avaliadas conjuntamente em R\$ 500,00, as quais haviam sido furtadas entre os dias 16 de outubro de 2021, conforme o boletim de ocorrência nº 6342/2021.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/15 e 16/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23 e 119), auto de avaliação (fls. 24), auto de entrega (fls. 25), laudo de constatação (fls. 31/32) e exame químico-toxicológico (fls. 199/200).

O acusado Pablo foi notificado (fls. 240), apresentou resposta escrita (fls. 166/180) e a denúncia foi recebida exclusivamente quanto aos delitos previstos no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 e art. 180, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, tendo sido rejeitada quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 (fls. 201/207).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia, quanto aos delitos de tráfico e receptação, reconhecimento da reincidência e maus antecedentes, e regime inicial fechado. (SAJ)

Em sede de memoriais, a Defesa, por seu turno, preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa diante da negativa da realização do exame para atestar a dependência de drogas. No mérito, pugnou pela absolvição nos termos do art. 386, inciso V, do CPP. Subsidiariamente, requereu a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06; e em caso de condenação, pugnou pela aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da mesma Lei. (fls. 293/303)

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade processual sob alegação de cerceamento de defesa diante da não realização do exame de dependência química toxicológica no réu.

Conforme já dito anteriormente, tem-se que os documentos juntados às fls. 181/187 são insuficientes para indicar a dependência química com comprometimento cognitivo, tratando-se de comprovante de agendamento de avaliação psiquiátrica, receituários médicos e fotos sem data e desvinculadas de documento comprobatório da alegada overdose com parada cardíaca sofrida pelo réu, em tese, no mesmo dia em que foi preso em flagrante.

Nesse sentido, dá análise dos autos não se vislumbra qualquer indício de que o acusado ostente comprometimento parcial ou total de sua capacidade cognitiva em razão da alegada dependência, circunstância essa que também não se evidenciou quando da realização da audiência de instrução.

Como se vê, quando interrogado na fase inquisitiva e em Juízo o réu respondeu com absoluta lucidez todos os questionamentos que lhe foram formulados, de modo que inexistente fundada dúvida acerca de sua integridade mental, tampouco subsistem traços de comprometimento do poder de autodeterminação do réu no momento de perpetração do delito, o que seria imprescindível para instauração do incidente, conforme disposto nos arts. 149 e 184, ambos do Código de Processo Penal.

É pacífico na jurisprudência pátria que a mera alegação de que o acusado é usuário de drogas não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, sendo necessário frisar que a referida arguição de nulidade apresentou-se desacompanhada da prova de eventual prejuízo ao réu, de acordo com o disposto nos arts. 563 e 571, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE CAUSÍDICO. CONDENAÇÃO. PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Refutar as conclusões a que chegou ao Tribunal de origem no sentido de que há lastro probatório idôneo à manutenção da decisão condenatória encontra óbice no enunciado 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior. II - "[...] a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie" (AgRg no RHC n. 109.459/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020). III - No caso, além de inexistir mácula processual porquanto houve intimação do órgão ao qual estava a referida Procuradora do Estado vinculada, está-se diante de diminuição da reprimenda imposta em primeiro grau, o que denota a ausência de prejuízo ao ora agravante. IV - "O interrogatório, no período anterior à Lei 10.792/2003, era entendido como ato personalíssimo do magistrado, não se submetendo ao princípio do contraditório, o que inviabilizava a intervenção da acusação ou da defesa, motivo pelo qual a ausência de defensor não implica qualquer nulidade" (HC n. 301.272/SP, Quinta Turma, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 13/11/2014). V - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1508913 SP 2019/0153517-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020) g.N.

Também não há que se olvidar que a análise da necessidade de realização do exame de dependência toxicológica situa-se no âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado.

Assim, no presente caso não resta outra alternativa senão rejeitar a presente preliminar de nulidade, pois não restou devidamente demonstrado ao menos a plausibilidade da alegação com outros elementos de prova, seja documental, seja de outra natureza ou ainda indícios contundentes da dependência toxicológica do acusado para que fosse determinada a realização do exame.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

Atestado em ambos os laudos que a substância apreendidas consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 13/15 e 16/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23 e 119), auto de avaliação (fls. 24), auto de entrega (fls. 25), laudo de constatação (fls. 31/32) e exame químico-toxicológico (fls. 199/200).

A autoria foi demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que na data dos fatos

autorizou os policiais entrarem em sua residência. Negou que estava exercendo o tráfico de drogas e que as pedras de crack apreendidas, que estavam em sua residência, eram para seu uso próprio. Informou que se mudou para sua atual residência há dois dias e que as duas cadeiras já estavam na residência. Não tem conhecimento de quem levou as cadeiras para lá, não sabia que eram furtadas. Desconhece também a existência da munição de revólver que estava em sua residência. Afirmou que sua residência fica dentro do chamado "Beco", conhecido ponto de venda de drogas. Negou exercer o tráfico de drogas, ter furtado ou comprado as cadeiras furtadas e ter algum conhecimento a respeito da munição (fls. 09).

Em juízo, o réu declarou que fazia oito dias que havia se mudado quando a polícia adentrou na residência. As cadeiras já estavam no local quando se mudou, junto com um colchão e outros itens. Dormia com frequência no quintal, visto que era usuário de crack e passava noites acordado. No dia dos fatos, quando os policiais chegaram, estava usando crack. Permitiu que eles entrassem e entregou seu cachimbo juntamente com a droga nas mãos do policial Gustavo. Foi questionado pelos policiais a respeito das cadeiras mas respondeu que não sabe a procedência de tais itens, inclusive estava utilizando-as para colocar uma lâmpada. No interior da residência, na cozinha, foi encontrada uma balança, de uso próprio da sua esposa, a qual trabalha com panificação e faz salgados para o bar na esquina. Sua esposa também trabalha vendendo produtos do OBoticário e tinha uma quantia em dinheiro dentro de uma caixa. Quanto às 07 pedras de crack, disse que eram para seu consumo e que estavam em cima da sapateira. Com relação à munição, disse que nada sabe a respeito, pois não tem arma. Esta foi encontrada no corredor entre as duas casas. Reside na casa dos fundos e o local tem acesso à muita gente. No interior de sua casa foi encontrada apenas a balança. No quintal foram localizados os demais itens. Já foi internado anteriormente em Pirassununga para tratamento contra as drogas, onde permaneceu por um ano. (SAJ)

A testemunha de acusação, Jorge Luiz Bizarro Teixeira, investigador de polícia, declarou que receberam a informação de que Pablo teria recebido mercadorias subtraídas de uma clínica. Diante disso, averiguaram a residência dele e localizaram duas cadeiras que eram produtos do furto que investigavam, além de algumas porções de crack, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão. Em continuidade às diligências, receberam a informação de que teriam itens em um ferro velho próximo à residência de Paulo, motivo pelo qual se dirigiram até o local e lá encontraram a carcaça de um fogão e um aparelho de ar-condicionado desmontado. Informou que o investigador Gustavo estava no plantão no dia que houve o furto e a apreensão de parte dos objetos. Durante o plantão noturno, ele recebeu a informação de que haviam objetos na casa de Pablo e na manhã seguinte foram verificar. Acredita que Pablo tenha trocado as cadeiras por drogas, tendo em vista que os autores do furto foram identificados como sendo usuários de entorpecentes e Pablo já havia sido preso meses antes por tráfico, em outro endereço. Não participou da prisão e da identificação dos indivíduos que praticaram o furto. Com relação aos itens encontrados, Pablo alegou que não havia nada em sua casa e os acusou de terem colocado os itens no local. Afirmou que foram encontradas munições de calibre 32 na mesma caixa em que estavam os entorpecentes. Pablo não estava alterado no momento das buscas e não disse que era usuário de drogas. (SAJ)

Pois bem. De rigor a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio, bem como sua condenação pelo delito de receptação.

I) Da desclassificação do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o art. 28, "caput", da referida Lei.

Tem-se que a versão apresentada pelo réu de que a droga lhe pertencia e que é mero usuário de entorpecentes está em consonância aos elementos probatórios amealhados nos autos.

Verifica-se, no presente caso, que não foram apreendidos outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes em poder do réu e nenhum outro elemento foi trazido aos autos de forma a indicar a efetiva prática do tráfico de drogas por ele na data dos fatos.

Não se desconhece que para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente seja preso no ato da mercancia ou após vender a droga. Entretanto, é necessário que a destinação mercantil da droga apreendida seja devidamente comprovada, o que não ocorre nos presentes autos.

No presente caso, não foram presenciados atos de venda e não há histórico dele com o tráfico de drogas.

Como se não bastasse, não foram apreendidos outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes e outros trabalhos policiais para vinculá-lo à mercancia ilícita não foram realizados.

De outro lado, quanto aos entorpecentes localizados em poder do réu, cumpre salientar que a quantidade de drogas apreendidas (07 porções de crack, produto da cocaína, com peso líquido de aproximadamente 1,35g), apesar de não ser ínfima, não está a descaracterizar a destinação de uso.

Por esses motivos, impossível a condenação no tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação do destino mercantil da droga apreendida, sendo de rigor a desclassificação do crime para o de porte de entorpecentes.

Conforme preceituado no artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Assim, da análise de todas as determinantes legais, concluo que o réu portava a droga localizada em seu poder para consumo próprio.

Não há que se falar em inconstitucionalidade do delito imputado ao réu, tendo em vista que a disposição contida no art. 28 da Lei nº 11.343/06 se trata de norma penal válida e eficaz, emanada do poder competente, que atende à política criminal adotada.

O fato de o referido dispositivo não prever pena privativa de liberdade, mas somente outras medidas, que visam a conscientização e recuperação do usuário de drogas, não retira o caráter criminal da conduta.

A condenação, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas. Presunções e indícios não ostentam aquela qualidade de certeza, pelo que não servem para fundamentar um decreto condenatório. Só a certeza probatória pode alicerçar uma condenação.

Destarte, conforme tenha sido apreendida substância entorpecente em poder do acusado, e o mesmo tenha confessado ser usuário, impõe-se a desclassificação do delito de tráfico para o de uso.

II) Do delito previsto no art. 180, "caput", do Código Penal.

Analisando-se o conjunto probatório, reputo que o crime de receptação também restou caracterizado.

O crime antecedente foi devidamente comprovado pela juntada do boletim de

ocorrência de fls. 13/15 e auto de entrega de fls. 25, pelo relato da vítima Ivonne na fase inquisitiva, bem como pelo depoimento do investigador de polícia ouvido em Juízo, que confirmou a ocorrência do furto e o encontro das duas cadeiras de escritório furtadas na residência do réu.

Como se vê, a versão apresentada pelo réu de que desconhecia a procedência das cadeiras, pois havia se mudado para a residência há oito dias e elas já estavam no local juntamente com um colchão e outros itens, não passa de uma tentativa de se fazer passar por inocente.

Ademais, o investigador de polícia que participou da prisão do réu apresentou relatos seguros e coerentes, no sentido de que tomaram conhecimento que Pablo teria recebido mercadorias subtraídas de uma clínica. Durante diligências na residência dele, localizaram duas cadeiras produtos do furto que investigavam. Disse que os autores do furto foram identificados como sendo usuários de entorpecentes, razão pela qual acredita que ele tenha trocado os entorpecentes pelas cadeiras.

Como é cediço, o delito de receptação se perfaz quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta coisa que sabe ser produto de crime.

No presente caso, as cadeiras de escritório provenientes da prática do furto foram encontradas na própria residência do réu, que autorizou a realização das buscas no local pelos investigadores de polícia, de modo que não é crível que ele não detinha conhecimento dos fatos.

Cumprе observar ainda, que não há nos autos nenhuma informação que afaste o dolo, pelo contrário, não se vislumbra qualquer documento ou justificativa que possa embasar seguramente a negativa apresentada pelo réu de que havia se mudado para o local há apenas oito dias e os objetos localizados já estavam ali.

De outro lado, tem-se que o réu Pablo não se desvencilhou do ônus de fazer prova em contrário acerca da receptação, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de modo que restou evidente detinha ciência da origem ilícita das cadeiras de escritório.

De acordo com a Jurisprudência, para que esteja configurada a receptação prevista no art. 180, "caput", do Código Penal, basta a comprovação de que o réu estava com o bem anteriormente furtado, sem comprovar a procedência do mesmo.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 2) INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para rever o entendimento firmado pela Corte de origem, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1991207 DF 2021/0327666-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) g.N.

Assim, os elementos probatórios amealhados no autos são suficientes para demonstrar

o elemento subjetivo descrito no "caput" do artigo 180 do Código Penal, bem como concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa das cadeiras de escritório, tornando-se, portanto, incabível sua absolvição.

Assim, contrariamente ao que foi sustentado pela Defesa, certo é que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização do réu pelos delitos previstos no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 180, "caput", do Código Penal, é medida de rigor.

III) Da dosimetria da pena

Acolhida, portanto, a tese acusatória, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena do réu.

Quanto ao delito de posse de drogas, tem-se que o réu é multirreincidente (fls. 144/159 e 232/234), o que demonstra sua personalidade desregrada.

Diante disso, reputo a pena de advertência insuficiente e aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 meses.

Quanto ao delito de receptação, respeitado o sistema trifásico, aumento a pena do réu em 1/6 em razão dos maus antecedentes (fls. 137 - processo 0000644-24.2007.8.26.0510; fls. 138, processo 0000928-32.2007.8.26.0510, fls. 140, processo 0005509-85.2010.8.26.0510). Assim, sua pena inicial será de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da multirreincidentência (fls. 139, processo 2969-20.2017 e fls. 140, processo 0005742-72.2016.8.26.0510 e fls. 141, processo 0010568-44.2016.8.26.0510) e aumento a pena do réu em mais 1/6. Assim, sua pena passará a 01 ano e 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Anoto que não há outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento de diminuição, de forma que torno as penas acima fixadas definitivas.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, diante da multirreincidentência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, conforme dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal, pois é multirreincidente e portador de maus antecedentes, sendo que a medida não se mostra socialmente recomendável. Pelos mesmos motivos, deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

O valor do dia-multa será fixado no mínimo legal, diante da falta de maiores informações a respeito de sua situação financeira.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, CONDENANDO-SE o acusado PABLO ROGÉRIO FIGUEIREDO à pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de três meses, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, bem como às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 180, "caput", do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direito, bem como de conceder o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos da fundamentação.

Determino a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenha sido feita.

O réu terá o direito de apelar em liberdade.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 14 de junho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA